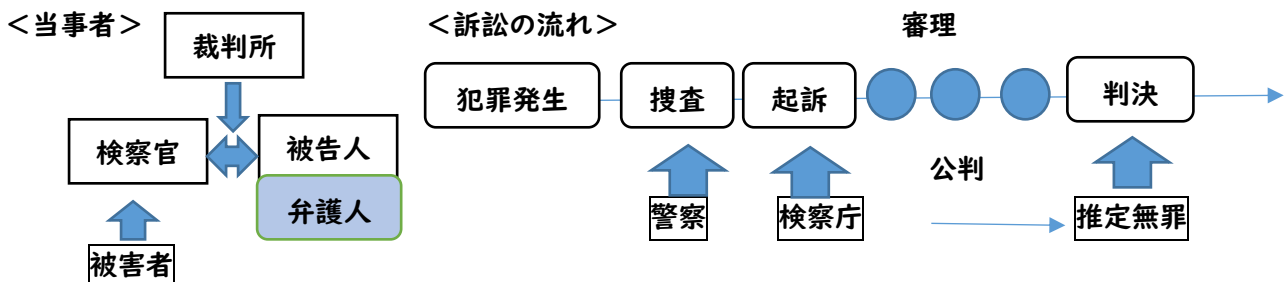


1、刑事手続の流れ

(1) 刑事訴訟の意義

- ①適正手続の保障…人権保障を全うする中での犯罪事実の解明 ※憲法 31 条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
→真実発見よりも、無実の者が誤って処罰されるようなことがあってはならない。
- ②当事者主義…検察官と被告人が対等な立場にたち、被告人の言い分を裁判で十分に聴聞
- ③疑わしきは被告人の利益に…検察官が被告人の犯罪を証明できなければ、有罪とすることはできない。

(2) 刑事裁判の関係者と流れ



2、刑法とは?…国家と個人との関係を規律

→犯罪と刑罰の内容を予め法律で定めることで、人の生命、身体、財産を守る。

(1) 刑法の基本原則…罪刑法定主義

→行為時、その行為を犯罪とし、刑罰を科する旨を定めた成文の法律がなければ、その行為を処罰することができない。=人権保障の見地から (刑罰=生命・身体・財産へ侵襲…慎重である必要)

⇒罪刑法定主義の派生原則

- ①慣習刑法の排斥…いかなる行為を犯罪とするかを成文法で定める。
- ②刑法の不遡及…事後に罰則を設けて、遡って処罰はできない。 ※刑法6条により軽減はOK
- ③類推解釈の禁止…適用範囲を不当に広げるもの。
- ④絶対的不定期刑の禁止…犯罪と刑罰の均衡、刑罰権行使の恣意の禁止。
- ⑤明確性の原則…処罰される行為が法文上明確でなければならない。

(2) 刑法の立場の対立⇒考え方・価値観の問題…刑法による処罰は、教育か制裁か?

ア、制裁…犯罪は行為者の問題=本人を罰することで、責任を取る。

イ、教育・更生…犯罪は行為者の環境=本人を教育することで、更生させる。

★刑罰論 (刑罰のあり方) と処遇論 (犯罪を行ったとされるものに対する処遇のあり方)

※応報刑法論…犯された犯罪に対し応報を加えるためだけに存在

※一般予防…潜在的犯罪者の威嚇を手段として犯罪防止を目指す消極的一般予防

遵法的市民の規範意識の維持・回復を手段とする積極的一般予防

※特別予防…刑罰は犯した犯罪の重さではなく、犯罪者の抱える再犯の危険に応じて科されることになる (刑罰の不公平、運用の不安定の問題) →犯罪者の威嚇や隔離を手段とする消極的一般予防

犯罪者の規範意識の向上を手段とする積極的特別予防

②刑法の法益

ア、国家的法益に対する罪＝国家の存立や作用等を侵害する罪(内乱罪、外患罪、公務執行妨害罪、偽証罪、賄賂罪など)

イ、社会的法益に対する罪＝公共安全・公共の信用・社会の風俗等に対する罪(騒乱罪、放火罪、往来妨害罪、通貨偽造罪、文書偽造罪など)

ウ、個人的法益に対する罪＝個人の生命・身体・自由・名誉・財産等に対する罪(殺人罪、傷害罪、逮捕・監禁罪、名誉毀損罪、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、盗品等に関する罪)

※詐欺事件：財産犯を離れて、公安目的化

例：料金を支払ってゴルフをした暴力団関係者に詐欺罪を認める事例(最判平成26年3月28日刑集68巻3号646頁)、貯金口座を開設させた暴力団関係者に詐欺を認めた事例(最判平成26年4月7日刑集68巻4号715頁)

③責任についての考え方…責任なければ刑罰なし、刑法の謙抑性・補充性

(3) 刑法総論＝犯罪の成立…犯罪成立に至る3段階

①構成要件該当性…犯罪の型＝刑法の条文に適合するか

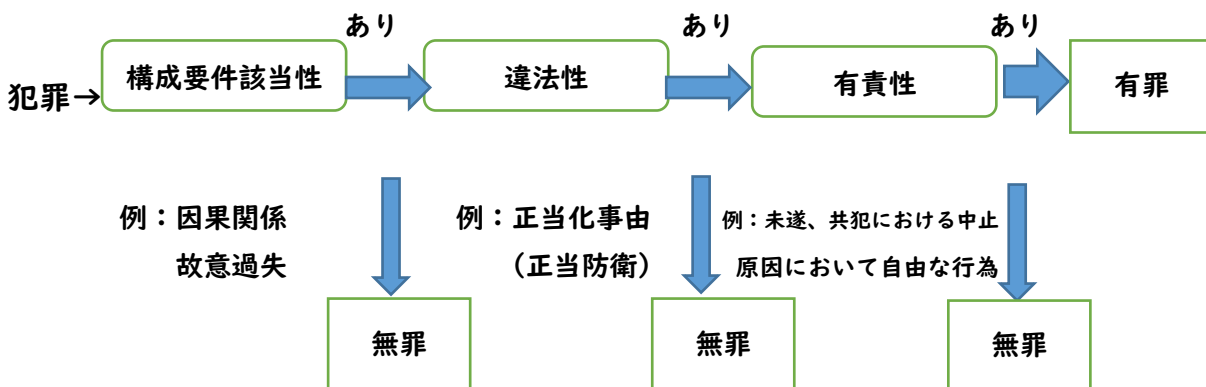
↓ 犯罪の型に当てはまらなければ、どんなに悪くても犯罪にならない

②違法性…違法阻却(例外事情)＝正当防衛や緊急避難はないか

↓ 行為によって得られる利益が被害の程度を上回るなら、処罰されない

③責任…不可抗力・責任能力＝責任能力はあるのか、共犯者は軽くないか
計画的か偶然か、子供か大人か

⇒刑法の基本プロセス



4、刑罰の重さと影響

★刑罰の変更…懲役・禁固から「拘禁刑」へ

(1) 死刑存置と死刑廃止の対立

①死刑存置(約60か国)…日本、アメリカ(州による)、中国→因果応報、被害者感情、囚人のコスト

※遺族や国民感情⇒死刑にすることで救われるか?

→修復的司法…被害者と加害者の和解、原状回復、損害賠償、家族集会、社会奉仕、補償、贖罪、賠償などとの関連＝犯罪に関係する当事者が会し、犯罪の影響と将来への関わりをいかに取扱うかを集団的に解決するプロセス

②死刑廃止(約100か国)…ヨーロッパ→人権、誤判のおそれ(数多くの再審無罪事例)、終身刑への代替

→終身刑の死角…誰が費用を支払うのか？→経済的負担は国民

(2) 実刑と執行猶予…社会的な制裁も考慮→社会復帰が前提 ※再犯の防止

→一定の要件のもとで、情状によって一定の期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間を無事に経過すれば刑の言い渡しはその効力を失うものとする。 ※軽い罪でも2回目は実刑

(3) 犯罪の動向…犯罪は減っているが、犯罪報道が多いため、凶悪犯罪が増えていると誤解。

→ラベリング論…その行為者に犯罪者というラベルを貼ることで、本人もそれを受け入れ、自分は犯罪者だというイメージを持つようになり、自分に対する社会の見方に合うように、自分の将来の構図を形作ろうとする結果、さらなる逸脱を行うという考え方。

(4) 少年法…教育による社会復帰の必要性→セカンドチャンスを許さない社会？

①少年法の意義…生育途上にある少年は可塑性(変化する可能性)があるため、その非行に対しては成人と同様に刑罰を加えるよりも、教育的方法によって処遇することが安心して暮らせる社会に繋がる。

③少年審判…要保護性(少年が再び非行を行うか否か)+非行事実⇒保護処分…少年院 or 保護観察
ア、少年院=生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導、社会復帰支援

イ、保護観察=就労支援

※出所後、再非行少年年率 34.9% 大人は 48%

⇒社会復帰支援は保護司に依存…保護司の高齢化、人的余裕なし、専門的知識の必要

※再犯するケース…戻っても家でDVを受け、戻るところは少年院しかなくなる。

5、構成要件該当性…故意、因果関係、行為など

(1) 故意について…確定的故意、不確定的故意

①確定的故意…具体的に確定している犯罪事実を認識

②不確定的故意

ア、概括的故意…いずれの客体に結果が発生するのか、その個数につき不確定な認識

例：群衆の中に石を投げる場合

イ、択一的故意…結果がいずれかの客体かに発生することは確定しているがいずれか不確定な認識

例：A・Bのどちらかを殺すつもりで発砲

ウ、未必的故意…結果発生の可能性を認識し、かつこれを認容する場合

例：人をはねてもいいと思ってスピードを出し、人身事故

(2) 因果関係について…条件説、相当因果関係説

①因果関係の考え方

例1：大阪南港事件(最判平成2年11月20日)…Yは、Xによってボコボコにされ、意識を失った。XはYを大阪湾の倉庫に置き去りにして、その場を去った。その後、Yの遺体が発見される。Xが捕まり裁判になったが、実は、Xが放置した後、誰かが角材でYをぶん殴り、それが原因で死亡していることが判明した。Xの行為とYの死亡には、因果関係があるのか？(もし、因果関係ありなら殺人罪、なしなら傷害罪)

ア、条件説(判例)…その行為が無かったらその結果も発生しなかったらう⇒Xは傷害致死罪

イ、相当因果関係説(学説)…その行為からその結果が発生することが一般的ならOK⇒Xは傷害罪

⇒もし、判例の条件説の場合、次のようなケースはどうか？

例2：怪我と交通事故の因果関係…Yは、Xとケンカをして殴られて、病院に搬送された。しかし、救急車が途中交通事故を起こしてしまい、Xは事故死した。Xの死亡とYの行為に因果関係はあるのか？

→納得のいかない結果（Xは傷害致死罪）になる！？

例3：択一的競合…Aは、大嫌いなCを苦しませようとして、致死量に満たない毒をコーヒーに注いだ。しかし、その時、同じようにBもCを憎んで致死量に満たない毒をコーヒーに入れていた。結果、Cは死亡した。Aの行為とCの死亡の間に因果関係はあるのか？

→この場合、Aの行為なくCは死亡することがないため、Aの行為とCの死亡に因果関係はあり。（AもBも殺人罪）

例4：AもBも致死量の毒を入れていたらどうなるか？

→Aの行為なくとも、Cは死亡する。Bの行為なくともCは死亡する。そうすると、「あればこれなし」の法則が崩れ、AもBも殺人の因果関係がなくなってしまう論理的矛盾が起こる。判例では、修正説という苦し紛れの説でこの場合も両者を殺人罪にしている。

②因果関係の判断基底

例：血友病事例…Aはイライラしていたため、道でぶつかったBを殴った。ところが、Bは血友病患者で、血が止まらず、死亡した。Aの罪責は？

→因果関係があるかどうかは、客観的に判断できるが、加害者の意思と乖離する場合がある。Aの行為とBの死亡の関係は因果関係があるように見えるが、普通は殴った位で死ぬとは思わない。

- ア、主観説…Bが血友病だということをAが認識していたかどうか
- イ、客観説…事実として、Bが血友病かどうか
- ウ、折衷説…Bが血友病ということを一般的に認識可能かどうか（判例）

6、違法性…法益侵害ないし危険というマイナスを帳消しにする事情→正当行為、正当防衛など

（1）違法性の本質…何が違法なのか？

①主観的違法論…法の命令に反して人が行為することを違法ととらえる。

→行為無価値（意思に基づく行為に注目）

②客観的違法論…行為から生じる事態が好ましくないという評価が先行する。

→結果無価値（発生した結果に注目）

例：空ピストル事件…Aは警察官Bに逮捕されそうになったため、Bを殺して逃走しようと思い、Bが携行していた拳銃を奪って、Bに銃口を当て2回引き金を引いたが、たまたま実弾が入っていなかったため何も起きなかった。Aは、罪に問われるか？

ア、行為無価値…殺人未遂罪 イ、結果無価値…不能犯

例：AはBを殺したが、BもAを殺そうとしていた（偶然防衛）。Aは罪に問われるか？

ア、行為無価値…防衛意思必要：なければ殺人罪 イ、結果無価値…防衛意思不要：正当防衛

（2）正当行為…法令が一定の構成要件該当行為を許容

→例：臓器移植…脳死した人の身体から臓器を摘出→死体損壊罪の構成要件に該当するも、臓器移植法に基づく法令行為として違法性阻却

①安楽死…死に際して患者の苦痛を緩和し、または除去すること。

ア、純粋安楽死…死に際して苦痛を感じないような措置を取ることに

イ、消極的安楽死…治療措置によって患者の生命を一定限度維持することができるが、それによる苦痛がある場合、治療を中止して患者の生命を引き延ばさないこと

ウ、間接的安楽死…苦痛を緩和する措置によって、副作用として生命を短縮すること

エ、積極的安楽死…生命を断つことによって患者を苦痛から解放する措置のこと

※例：東海大学安楽死事件：東海大学医学部付属病院に多発性骨髄腫で入院していた男性患者の長男等から「苦しむ姿を見てられない」と治療行為の中止を求められ、迷った末、点滴やフォーリーカテーテル等を外して治療行為を中止したが、その後も、荒い苦しそうな呼吸をしている患者を診ていた長男から「楽にしてやってほしい。早く家につれて帰りたい。」などと再三言われたことから、末期状態にあり死が迫っていたこの男性患者に息を引き取らせることを決意し、塩化カリウム製剤等の薬物を同人に注射して死亡させた。医師の責任が問われた

→横浜地裁は、①耐え難い肉体的苦痛があること、②死が避けられずその死期が迫っていること、③肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと、④生命の短縮を承諾する明示の意思表示があること、の要件で認められるが本件は該当せず、殺人罪として、懲役2年執行猶予2年とした。

②尊厳死…新たな延命技術の開発により患者が医療の客体にされることに対抗すべく、人口延命治療を拒否し、医師が患者をしに行くに任せることを許容すること 例：カレン・クインラン事件

＝望まない治療を強制されないこと

(3) 正当防衛…正 VS 不正

(刑法36条) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は罰しない。

①「急迫不正の侵害」…積極的加害の意図（その機会を利用した返り討ち）は急迫性を失う。

②「自己又は他人の権利の防衛」…対物防衛の場合、違法な侵害行為ではないとの評価になる。

※人間が襲う場合には認められるが、動物が襲う場合には認められない。

③「やむを得ず」…偶然防衛の場合、防衛の意思が必要になる。（行為無価値）

※正当防衛の厳格化（最判平成29年4月26日刑集71巻4号275頁）

「刑法36条は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである」

「前記のような刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の窮迫性の要件を満たさないものというべきである」＝正当防衛の急迫性への一元化

→救助に來た警察官と共にする防衛も、また警察官自身による防衛も、侵害の急迫性がないため許されなくなってしまう

(4) 緊急避難…緩和された正当防衛＝正 VS 正

(刑法37条) 自己又は他人の生命、身体、自由、又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。（以下略）

- ①現在の危難…切迫しているということ
- ②やむを得ずにした行為…補充の原則(危難を避ける唯一の手段であること)
- ③避難行為から生じた害<避けようとした害…法益均衡の原則
- ④特別の義務が無いこと

※例：カルネアデスの板

一隻の船が難破し、乗組員は全員海に投げ出され、一人の男が命からがら、壊れた船の板切れにすがりついた。するとそこへもう一人、同じ板につかまろうとする者が現れた。しかし、二人がつかまれば板そのものが沈んでしまうと考えた男は、後から来た者を突き飛ばして水死させてしまった。その後、救助された男は殺人の罪で裁判にかけられた。この男は罪になるか？

※例：トロッコ問題

線路を走っていたトロッコの制御が不能になった。このままでは前方で作業中だった5人が猛スピードのトロッコに避ける間もなく轢き殺されてしまう。
→あなたは、線路の分岐器のすぐ側にいる。あなたがトロッコの進路を切り替えれば5人は確実に助かる。しかしその別路線でも1人で作業しており、切り替えるとトロッコに轢かれて確実に死ぬ。あなたは、どうすべきか？トロッコを別路線に引き込むべきか？

★誤想防衛について…急迫不正の侵害の存在が存在しないのにそれがあった者と誤信して防衛行為に出た場合、急迫不正の侵害に対して相当な防衛行為をするつもりで不相当な行為をした場合＝犯罪成立

★過剰防衛について

例：勘違い騎士道事件(最判昭和62年3月26日)＝空手三段のイギリス人が夜間帰宅中に酩酊した女性がこれをなだめる同僚ともみ合うのを見て、同僚が女性に暴行を加えていると誤解し、割って入ったら、同僚がファイティングポーズをしたので、自分を殴ると誤信して、回し蹴りをしたところ、後頭部に直撃し頭蓋骨骨折をして死亡してしまった事件。1審は無罪だったが、2審は誤想過剰防衛として、傷害致死罪で懲役1年6か月、執行猶予3年とした。最高裁は上告棄却。

7、有責性…非難ないし非難可能性

(1) 違法性の認識について

例：たぬき・むじな事件(大判大正14年6月9日)＝狩猟法により捕獲禁止期間中に、タヌキを地方で通俗的に十文字貉(むじな)と呼ばれている獣であったタヌキとは別個のものと誤診して捕獲し殺し事件。⇒別種であると信じており、社会的意味の認識を欠いているため、違法性の認識なしとして無罪。

(2) 責任能力…違法性を弁識していること(自己の制御)

(刑法39条)心神喪失者の行為は、その敬を減刑する。

→心神喪失・耗弱者(精神障害を持っている者)、刑事未成年者(14歳)

※責任能力…正常か異常か→米国精神医学会のDMS、世界保健機関のICDD…症状の程度を重視

→責任能力は「全くないとはいえない」ので、心神喪失、心神耗弱は認められにくい(少しでも了解可能な行動がみられる場合には、心神喪失の判断を回避)